

1501011-02.2022.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

FABIO PEREIRA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

FÁBIO PEREIRA foi denunciado e está processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04.07.2022, por volta das 20h50min, na Rua Sineval Caviquioli, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1501011-02.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

FABIO PEREIRA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

FÁBIO PEREIRA foi denunciado e está processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04.07.2022, por volta das 20h50min, na Rua Sineval Caviquioli, Guapurá, nesta cidade e comarca de Itanhaém, o agente supra apontado trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) papелotes de cocaína e 152 (cento e cinquenta e duas) porções da droga Cannabis sativa L, conhecida por maconha, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14.07.2022 (págs. 131/132).

O réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (págs. 148/152).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma pela Defesa, seguindo-se o interrogatório do réu (págs. 224/225).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-o nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição em razão da nulidade na busca pessoal ou, subsidiariamente, que seja observada a atenuante de confissão espontânea e compensada com a agravante de reincidência, bem como possa apelar em liberdade e fixada o regime inicial em semiaberto e a reavaliação da prisão preventiva.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A nulidade da busca pessoal/veicular formulada pela Defesa, não merece ser acolhida, tendo em vista que a busca se deu pela existência de fundada suspeita para que fosse tomada a medida extrema, não se podendo falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas, tudo encontrado no interior do veículo do acusado.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

Ao mérito, pois.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01), pelo boletim de ocorrência (págs. 18/21), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 27/28), pelo auto de constatação preliminar (pág. 26), pelo laudo pericial (págs. 193/199), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução (págs. 141/142).

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, Esmeraldo Gomes de Novaes Junior, ouvido em Juízo, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Guapurá quando avistaram um veículo em alta velocidade, motivo pelo qual deram sinal de parada. Asseverou que quando se aproximaram do veículo notaram que o réu colocou uma sacola plástica embaixo do banco. Desse modo, devida a fundada suspeita de que houvesse entorpecentes na sacola, fora realizada a busca no veículo e encontrada a sacola com diversos entorpecentes. Por fim, indagado, Fabio admitiu que as drogas seriam para abastecer um ponto de tráfico.

A testemunha arrola acusação, Rafael Vianna Coelho, ouvido em Juízo, Policial Militar, relatou os mesmos fatos que seu colega de farda.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO

TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

A testemunha arrolada pela defesa, Daniela Alessandra Muniz, ouvida em Juízo, informou que os fatos não ocorreram conforme narrado pelos policiais, pois não havia drogas no interior do veículo.

O réu, Fábio Pereira, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava levando os entorpecentes para um ponto de drogas.

Pois bem.

A responsabilidade penal do réu é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos e a confissão espontânea, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta do réu, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício

que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Contudo, como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do réu, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor do réu.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 91/103) observo que o réu possui maus antecedentes, desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, como também a agravante da reincidência, conforme certidão (págs. 88/90), que é considerada preponderante sobre a atenuante conforme regra expressa

do artigo 67 do Código Penal. Diante disso, exacerbo a pena base em apenas 1/3 (um terço), resultando uma pena provisória de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete dias) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete dias) dias-multa.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu sendo reincidente impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Dito isso, presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), pela suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I e III do Código Penal), e a aplicação dos regimes aberto e semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal).

Assim, também o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Posto isto, CONDENO o réu FÁBIO PEREIRA qualificado nos autos, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete dias) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências

cabíveis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 30 de novembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA